

1501942-20.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... precedentes do E. TJSP:

Apelação: Defesa. Tráfico e associação para o tráfico: art. 33, caput, e art. 35, cc art. 40, VI, Lei 11.343/2006. Tráfico. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Associação criminosa: falta de provas de condutas indicativas de vínculo associativo. Pena-base: majoração por maus antecedentes e quantidade dos produtos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi-SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501942-20.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501942-20.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274013/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 20699523 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 370/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2274013 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DUTRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

PAULA CAVALCANTE DUTRA, FERNANDO DUTRA e AIRTON FREITAS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, no dia 06 de outubro de 2021, às 17h30min, na Rua Wladimir Vilhena Braga, altura do n.º 36, Jardim Sorocabana, nesta cidade e Comarca de Itapevi, os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, nas mesmas condições de tempo e local acima, os réus associaram-se para o

fim de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os réus foram notificados (f. 233-235) e apresentaram defesa prévia (f. 172-182, 240-251 e 256-261).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, a exordial acusatória foi recebida por decisão datada de 1.º de fevereiro de 2022 (f. 281-284).

Os réus foram citados, dando-se seguimento à persecução penal em Juízo.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas, tendo-se interrogado os réus ao final (f. 236). Na sequência, encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (f. 234-235).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa aos acusados a prática das infrações penais previstas nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de f. 12-13, que atesta terem sido apreendidos os entorpecentes no local indicado na denúncia.

As substâncias entorpecentes foram submetidas a exame pericial (f. 142-145), sendo que o resultado foi positivo para "crack", "cocaína" e "maconha", drogas de uso proscrito no Brasil.

Por outro lado, restou comprovada apenas a autoria de Airton Freitas de Oliveira.

Observe-se.

O corréu, em seu interrogatório, confessou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória.

A confissão, aliás, restou corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram contestes nos pontos essenciais e confirmaram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

Relatam que receberam uma denúncia anônima de que havia uma quadrilha que distribuía drogas na região de Itapevi. Iniciaram, então, uma pesquisa de campo e descobriram que, no local dos fatos, haveria o armazenamento das drogas. Fizeram campana lá em dias alternados e viram algumas vezes a acusada Paula Cavalcante Dutra sair da residência com uma sacola e retornar sem nada. Dois dias depois do início da campana abordaram a ré, que disse não haver nada ilícito no imóvel e franqueou a entrada no local. A porta da casa estava aberta e os outros dois réus estavam sentados lá dentro. Revistaram a casa e encontraram as drogas em cima do guarda-roupa. O acusado Airton Freitas de Oliveira afirmou que as drogas eram dele. Abordaram, então, os três acusados.

E nada há nos autos que indique eventual intenção espúria dos policiais civis de incriminar injustamente o acusado. Assim, seus depoimentos merecem credibilidade e são valiosos para a condenação. Entendimento contrário acarretaria a ruína do sistema de segurança pública do Estado.

Frise-se, nesse passo, que as circunstâncias da abordagem, noticiadas nos depoimentos dos policiais civis, permitem presumir que as drogas apreendidas com o acusado se destinavam ao tráfico, não havendo espaço para eventual desclassificação da conduta praticada.

Todavia, não há elementos probatórios que amparem a condenação dos acusados Paula Cavalcante Dutra e Fernando Dutra.

Os réus, em solo policial, negaram a prática delitiva e afirmaram ser usuários de drogas e desconhecer que havia entorpecentes no interior da residência. Fernando Dutra disse que estava na casa da irmã pois iam juntos à piscina do bairro, e Paula Cavalcante Dutra afirmou que morava naquela casa, mas não sabia que seu marido guardava os entorpecentes no local (f. 10-11 e 15-16).

Em juízo, mantiveram a coerência e apresentaram a mesma versão dos fatos. Negaram

ter ciência da existência de drogas no imóvel.

A ré Paula Cavalcante Dutra afirma que as drogas estavam no cômodo que existia ao lado da residência dela, não dentro da própria casa, e que o seu marido, o réu Airton Freitas de Oliveira, havia alugado o cômodo para um amigo que estava precisando. O seu irmão, Fernando Dutra, estava no local apenas porque os dois iam à piscina; não ia lá com frequência. As drogas pertenciam apenas ao acusado Airton Freitas de Oliveira.

Já o réu Fernando Dutra assevera que, na data dos fatos, foi à casa da sua irmã porque eles haviam combinado de ir à piscina; nada sabia sobre as drogas existentes no imóvel.

O acusado Airton Freitas de Oliveira corroborou essas alegações. Em seu interrogatório, afirma que era o único que estava armazenando as drogas no local, num cômodo vazio ao lado de sua casa, e que os demais acusados não têm relação com os entorpecentes.

Importante ressaltar, ainda, que os policiais civis não viram a acusada Paula Cavalcante Dutra em posse de drogas; não viram o que havia nas sacolas que ela carregou nos dois dias anteriores à abordagem.

Outrossim, o réu Fernando Dutra não foi visto pelos policiais civis durante a campanha que antecedeu a prisão em flagrante.

Nesses termos, impõe-se a absolvição dos réus Paula Cavalcante Dutra e Fernando Dutra, nos termos do art. 386, V, do CPP, já que ausentes provas de seus envolvimento no delito de tráfico.

No que tange ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, que também foi imputado aos acusados, a improcedência dessa acusação é corolário da absolvição dos réus Paula Cavalcante Dutra e Fernando Dutra.

Ora, não havendo o envolvimento dos acusados no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há como configurar-se a associação, que exige a participação de duas ou mais pessoas.

As provas, portanto, são bastantes apenas para a condenação do réu Airton Freitas de Oliveira, e tão somente pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006).

No que tange à aplicação da circunstância privilegiadora, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, revendo posicionamento anterior e tendo em vista os recentes julgados dos tribunais superiores sobre o assunto, não vislumbro inconstitucionalidade na incidência da causa de diminuição de pena.

Explica-se.

A Terceira Seção do C. STJ, embora não tenha se pronunciado diretamente sobre a inconstitucionalidade ou não da causa especial de diminuição de pena em tela, ao revisar o REsp n.º 1.329.088/RS, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC), no Tema n.º 600, firmou a seguinte tese: "O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo".

Com a revisão da tese anterior, o tribunal superior cancelou seu enunciado de súmula n.º 512, que assim dispunha: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas".

Foram, outrossim, compiladas as seguintes teses sobre o tema, na edição n.º 131 da Jurisprudência em Teses do C. STJ:

21) O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600)

22) A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes.

23) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.

25) Diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da

causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito.

45) A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem.

46) A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF.

48) A utilização da reincidência como agravante genérica é circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico, e não caracteriza bis in idem.

Em todos esses enunciados, bem como no Tema Repetitivo n.º 600, o C. STJ admitiu indiretamente a viabilidade de incidência da circunstância privilegiadora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, desde que observados cumulativamente os requisitos do dispositivo.

Também o STF firmou tese admitindo a aplicação da privilegiadora ao delito de tráfico, no julgamento do Tema n.º 712 de Repercussão Geral, no qual se firmou a seguinte tese: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". Desse modo, nada há que se falar sobre eventual inconstitucionalidade da norma disposta no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

No caso concreto, todavia, é incabível a aplicação da forma privilegiada do tráfico, eis que não observados cumulativamente todos os requisitos para sua aplicação.

Com efeito, o réu não preenche o primeiro requisito, pois é reincidente específico no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, consoante certidão de f. 315-317.

Inviável, nesses termos, a incidência da causa de diminuição de pena.

Há, pois, subsunção da conduta do acusado ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que, com vontade e consciência, guardava e tinha em depósito as porções de droga indicadas na denúncia, sem autorização legal ou regulamentar.

O fato é ilícito, pois reprovado pela lei penal, sendo que não foram alegadas ou comprovadas quaisquer causas justificantes.

O denunciado era maior de 18 anos de idade (imputável), tinha potencial consciência da ilicitude e, nas circunstâncias, era-lhe exigida conduta diversa. Presente, portanto, a culpabilidade.

Em razão do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para: (a) absolver os réus PAULA CAVALCANTE DUTRA e FERNANDO DUTRA das imputações indicadas na denúncia, na forma do art. 386, V e VII, do CPP; (b) absolver o réu AIRTON FREITAS DE OLIVEIRA da imputação relativa ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, na forma do art. 386, VII, do CPP; e (c) condenar o réu AIRTON FREITAS DE OLIVEIRA, já qualificado, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Assim, passo a aplicar a pena, seguindo o método trifásico previsto no art. 68 do CP.

Inicialmente destaco que este Juízo, para a estipulação da pena base e o cálculo do aumento decorrente de eventual circunstância judicial – inclusive para a aferição de pena de multa cominada isolada ou cumulativamente –, leva em consideração o resultado do intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt: "O critério que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta

proporcionalidade), o qual servirá de parâmetro para o julgador promover suas análises individuais" (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Podivm. 6ª edição. Salvador/Bahia. 2011. p. 115/116).

A par disso, para a hipótese específica destes autos, incide o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que assim dispõe, in verbis: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Neste cenário normativo, verifica-se que dois vetores do art. 42 da Lei de Drogas já estão inseridos expressamente nos parâmetros do art. 59 do CP - "personalidade e conduta social do agente". Outrossim, tem-se que "a natureza e a quantidade da substância ou produto" podem ser analisadas no contexto das "circunstâncias" do delito, outro vetor do art. 59 do CP.

Assim, e pela necessidade da "preponderância" prevista no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, alvitra-se valorar a personalidade e a conduta social do agente, assim como as circunstâncias do delito, com um peso mais significativo.

Como ressaltado anteriormente, costuma-se considerar o intervalo, abstratamente previsto pela lei, entre a pena mínima e a pena máxima, seguido da divisão por oito. Todavia, para preponderância aqui perseguida, prudente que a divisão seja feita por 11, uma vez que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas podem ser enquadradas em três vetores, tal como delineado acima - personalidade, conduta social e circunstâncias.

Fazendo isso, porém, deve-se dar aos vetores preponderantes o peso de 2/11, e aos demais, o de 1/11.

Assim, nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/06, à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (irrelevante em se tratando de crime vago como o tráfico de drogas), deve-se atribuir o peso de 1/11, constituindo 5/11 da pena-base; à conduta social e à personalidade do agente, assim como às circunstâncias, deve-se aplicar o peso de 2/11, configurando 6/11 da pena-base.

Desse modo, estará garantida a aplicação preponderante do art. 42 da Lei de Drogas, bem como assegurada, de forma mais escorreita e técnica, a individualização da pena.

Todavia, é necessário ressaltar que a fração indicada não deve ser aplicada de forma precisa, matematicamente. Trata-se, na verdade, de mero parâmetro para a fixação da reprimenda penal, de modo que as circunstâncias do caso concreto podem ensejar a exasperação maior ou menor da pena - ou maior ou menor compensação em caso de vetores favoráveis.

Feitas essas observações, à dosimetria da pena.

Pois bem, o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas será considerada nesta primeira fase, pois caracteriza Maus Antecedentes, e a outra será sopesada na segunda fase da dosimetria.

A par disso, importante ressaltar que as circunstâncias do delito de tráfico são desfavoráveis. Com efeito, o denunciado estava na posse de entorpecentes de naturezas diversas, maconha (em três formas - "haxixe", "skunk" e "baseado"), cocaína e crack, essa última de altíssimo poder destrutivo. Outrossim, a quantidade dos entorpecentes apreendidos foi significativa (75g de crack, 354,3g de cocaína, 437,6g de maconha, 12,3g de skunk e 35,2g de haxixe - f. 142-145).

As demais circunstâncias do art. 59 do CP não são desfavoráveis ao réu, ou são normais ao tipo penal.

Nesse contexto, havendo duas circunstâncias judiciais negativas, uma delas preponderante, fixo a pena base em 7 anos e 8 meses de reclusão - e 766 dias-multa. Na segunda fase, há a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d" do CP, tendo em vista que o acusado confessou em juízo a prática do delito.

Há, outrossim, a agravante da reincidência, tendo em vista que, conforme certidão de f. 315, o acusado cometeu o crime em tela depois de ter sido condenado definitivamente por outro delito, tal como dispõem os arts. 63 e 64, I, ambos do CP.

No ponto, ressalto que o acusado é reincidente específico, pois foi condenado anteriormente também por tráfico ilícito de entorpecentes, o que, se não coubesse a compensação com a atenuante apontada, reclamaria uma exasperação mais severa do que a fração habitualmente utilizada de 1/6.

No caso concreto, todavia, ante a agravante da reincidência específica, a compensação deve ser apenas parcial, na esteira de precedentes do E. TJSP: Apelação: Defesa. Tráfico e associação para o tráfico: art. 33, caput, e art. 35, cc art. 40, VI, Lei 11.343/2006. Tráfico. Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação. Associação criminosa: falta de provas de condutas indicativas de vínculo associativo. Pena-base: majoração por maus antecedentes e quantidade dos produtos apreendidos. Readequação. Fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, prevalecendo o acréscimo de 1/3. Condenações anteriores: consideração como maus antecedentes e reincidência, que "não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda" (STJ). Reincidência específica: impossibilidade de compensação integral com a atenuante da confissão. Confissão, todavia, adotada como elemento de convicção. Acréscimo de 1/8 pela circunstância prevalente. Aliciamento de adolescente: art. 40, VI, Lei 11.343/2006. Acréscimo de 1/6. Regime fechado: adequação, ante a pena fixada, antecedentes e reincidência. Recurso provido em parte, para readequação da pena em relação ao tráfico e absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. (TJSP, Apelação Criminal n.º 1500183-87.2020.8.26.0585, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Bueno de Camargo, julgado em 30/03/2022)

Assim, ante a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, compenso-as apenas parcialmente, e aumento a reprimenda em 1/8, fixando-a provisoriamente em 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão – e 861 dias-multa.

Por fim, na última fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, fixo a reprimenda, agora definitivamente, em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – e 861 (oitocentos e sessenta e um) dias-multa.

O valor do dia-multa fica estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país na data dos fatos, considerada a presumida precariedade da situação financeira do denunciado, valor a ser atualizado quando do efetivo pagamento. De acordo com o art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalte-se, nesse passo, que é inconstitucional a Lei n.º 12.736/2012, que determina a consideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Isso porque viola o princípio constitucional da isonomia, já que, aplicando-se a referida lei, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais. Assim, o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade, e que tenha sido preso provisoriamente, terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovido de regime sem a observância do seu comportamento carcerário (requisito subjetivo). Por outro lado, o condenado que não tenha cumprido prisão provisória deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5.º, caput).

Dessa forma, deixo de aplicar a Lei n.º 12.736/2012.

A detração deverá ser observada pelo juízo da execução, não havendo qualquer prejuízo ao acusado.

Mantenho a custódia cautelar do denunciado Airton Freitas de Oliveira, pois não modificadas as situações que determinaram a sua necessidade. Recomendo o réu na prisão onde se encontra. Expeça-se a guia de execução provisória.

Incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, arts. 44, inciso I, e 77, caput).

Em relação aos acusados absolvidos, já houve a expedição de alvará de soltura clausulado.

Determino a perda de eventuais bens apreendidos a favor da União, nos termos dos arts. 91, II, do CP e 63, I, da Lei n.º 11.343/2006.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do art. 387, IV, do CPP, pois se trata de crime vago.

Custas pelo réu (CPP, art. 804), no valor de 100 UFESPs (Lei n.º 11.608/2003, art. 4.º, § 9.º, "a"), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que agora lhe fica deferida, anotando-se.

Após o trânsito em julgado:

- (a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados ou instituto equivalente;
- (b) expeça-se a guia de execução definitiva;
- (c) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada do inteiro teor da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelo art. 71, § 2º, do Código Eleitoral combinado com o art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- (d) oficie-se ao Senad, nos termos do art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, se for o caso; e
- (e) arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

P.I.C.

Itapevi, 05 de abril de 2022.